

1500043-08.2022.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/08/2022
... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500043-08.2022.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006179/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22323909 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2006179 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS ALBERTO ARRUDA DE CAMARGO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

CARLOS ALBERTO ARRUDA DE CAMARGO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 07

de janeiro de 2022, na rua Dona Carolina, 235, Praça da Bíblia, nesta cidade e Comarca, nas imediações de uma praça pública, guardava, para consumo de terceiros, 17 pedras de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 143/144. Recebida a denúncia aos 04 de março de 2022 (fl. 146), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fl. 200) e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 231).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia e de seu aditamento, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 239/246).

A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade da prova que culminou com a prisão do acusado e a apreensão da droga, realizada por Guardas Municipais. No mérito, pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, além de combater a causa de aumento de pena denunciada, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 250/265).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente não assiste razão a defesa quanto à questão cogitada em preliminar. Diferentemente do acenado, descabido falar-se, na espécie, em prova ilícita, mercê da conduta dos guardas municipais. Isto porque não se vislumbrou durante a execução da prisão ação que ultrapassasse as raízes das funções que os agentes municipais estão autorizados a exercer.

Embora o texto da Constituição Federal que prevê a possibilidade da constituição da guarda municipal explicita que sua função consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do Município (artigo 144, parágrafo 8º), isto não significa que seus integrantes não ostentem a condição de agentes da autoridade, até porque o dispositivo acha-se inserido e há que se atentar para a interpretação sistemática, que sobreleva a puramente gramatical no capítulo da segurança pública.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que os guardas municipais estão "legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do Código de Processo Penal". E "se a lei autoriza

a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime" (RHC nº 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).

No mesmo sentido, "não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo" (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade em razão da prisão e apreensão das drogas ter sido feita por guardas municipais. Inconsistência. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha.

Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2.

Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 3. O grau de culpabilidade da conduta e a reincidência justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade

e obstam a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além da própria quantidade da sanção. 4. Penas inalteradas. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00228073920148260320 SP 0022807-39.2014.8.26.0320, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/06/2016)

Apelações. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos réus como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Recursos da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Situação de flagrante delito que justificava a prisão dos réus. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Penas inalteradas. Apelos improvidos. (TJ-SP - APL: 00137352120158260602 SP 0013735-21.2015.8.26.0602, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 16/03/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJ-SP - APL: 00014730920168260536 SP 0001473-09.2016.8.26.0536, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/10/2018)

HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal - Ilicitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva - Prova Ilícita - Falta de Justa Causal - Trancamento da Ação Penal - Não Verificado - Art. 301 do CPP - Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão - art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

No mérito, a materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/117) descreveu e concluiu que a substância analisada é cocaína, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração argumentando que não possuía nenhuma droga em seu poder.

Não há qualquer dúvida sobre a apreensão do entorpecente realizada durante a diligência, mesmo porque Noel não apresentou nenhuma circunstância que colocasse em dúvida a conduta dos guardas municipais. Não é crível que agentes públicos inventem fatos ou "enxertem" a droga em desfavor de acusados, em especial quando nenhum vestígio a respeito existe nos autos.

A par disto, ele não comprovou o exercício de atividade lícita, arguindo que parte do dinheiro encontrado em seu poder seria fruto de "esmolas" recebidas na via pública. De outra parte, quis fazer crer que a testemunha Anderson teria lhe entregado R\$ 20,00 com a finalidade de que fosse comprar drogas para ele. Desta forma, mostra-se sem origem o dinheiro localizado em seu poder e apreendido pelos guardas municipais.

Ele também não explicou com coerência o motivo de ter tentado fugir dos guardas municipais quando percebeu que seria realizada sua abordagem.

No mais, ele se escusou da imputação através de simples negatória geral, sem comprovar por quais motivos poderiam os guardas lhe imputar injustificadamente tal

crime.

Se não bastasse a força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Guarda Municipal Carlos esclareceu que naquela ocasião realizou patrulhamento num conhecido ponto de tráfico de drogas e se deparou com o acusado em típica atividade de venda de drogas, uma vez que observou o momento em que ele entregava algo para uma pessoa (testemunha Anderson). Contou que assim que notou a presença da viatura policial, o acusado tentou empreender fuga. Salientou que no momento em que ele fugia do local, observou-o com segurança arremessando um embrulho ao solo.

Realizada sua captura, revistou o agente e localizou em seu poder a quantia de R\$ 44,00, em dinheiro. Na sequência, retornou ao lugar onde o avistara dispensando um embrulho e o recolheu, constatando que havia 17 pedras de crack em seu interior. Acrescentou, ainda, que a pessoa que visualizou comprando drogas com o acusado também fora abordada pelos guardas municipais e confirmou que estava adquirindo drogas com Carlos Alberto.

Suas palavras são ratificadas pelo GM Marcos, que de forma séria e coerente narrou que, tão logo chegou ao local, observou o acusado entregando algo para uma pessoa, identificada posteriormente como Anderson, fato que motivou a abordagem aos envolvidos. Declarou, também, que perseguiu e capturou Anderson, oportunidade em que ele admitiu que comprava drogas com o acusado no instante em que os guardas ali chegaram.

Nada existe nos autos a demonstrar que os guardas responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Município, que auxiliam na repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos guardas que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido

naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local e a fuga do agente, assim como sua captura e revista pessoal, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos. Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhal colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código

Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Pontue-se que, durante a etapa policial, Anderson confirmou que naquela ocasião entregou ao acusado a quantia de R\$ 20,00.

Eis suas palavras:

"Que o declarante saiu da casa que estava usando droga nos Lavas Pés, que tinha R\$ 20,00 (vinte reais), que estava o Borel (acusado) sentado na praça, que então deu o dinheiro para ele para pegar o entorpecente, neste momento os Guardas apareceram, que o declarante saiu para um lado e ele para outro, que o "Borel" correu, e parece que dispensou o que tinha, mas não sabe informar o que, que um dos Guardas revistou o declarante e encontrou o cano que o mesmo utiliza para usar a drogas e os pirulitos, que então a polícia nós trouxe para Delegacia" - fl. 09.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a forma como estava acondicionada em porções prontas para a venda, o local, o dinheiro sem justificativa da origem, as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de coloca-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitacão do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afiml, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente às figuras "trazer consigo e guardar", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico. Inadmissível o pedido de desclassificação do delito imputado quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa e não da acusação o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser usuário e dependente, mesmo porque a condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário de droga.

Sobre a matéria:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem

dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha e possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, calibre 22, uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00008425720168260474 SP 0000842-57.2016.8.26.0474, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio, ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional para o início de cumprimento de pena e detração penal. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado colocar algo em sua boca em atitude suspeita, justificando sua abordagem. Realizada busca pessoal, RENAN cuspiu do interior de sua boca oito pedras de crack envoltas em papel alumínio. Ato contínuo, dando continuidade à busca, os milicianos encontraram em poder do acusado, mais especificamente no interior de suas vestes íntimas, trinta e quatro porções de maconha, todas acondicionadas separadamente em sacos plásticos. Ainda, no interior dos bolsos da bermuda que o denunciado vestia, os policiais apreenderam um celular Motorola e a quantia de R\$ 68,00 em espécie. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente específico que justifica o aumento adequado e proporcional aplicado pelo duto sentenciante, na segunda etapa da dosimetria da pena. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente a reincidência para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. 3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal. 4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00005459420188260566 SP 0000545-94.2018.8.26.0566, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente. Contudo, seus antecedentes recomendam exacerbação,

conforme indicam as certidões de fls. 48/51.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena. Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 52), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, suas penas serão elevadas em $1/6$ ($6 \text{ anos} + 1/6 = 7 \text{ anos}/600 \text{ dias} + 1/6 = 700 \text{ dias-multa}$), não havendo outras atenuantes ou agravantes genéricas a considerar.

Na etapa final deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III, uma vez que a prova é segura no sentido de que a infração foi praticada nas imediações de uma praça e de um estabelecimento de saúde.

O lugar do crime está a 35 metros de um posto de saúde e ao lado de uma praça, conforme certificou o laudo anexo (fls. 122/124). Logo, há proximidade entre os locais, verificando-se a influência e o potencial perigo que o comércio ilícito pode acarretar. Ressalte-se que para o reconhecimento da majorante não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente de fato atinja, diretamente, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.

Pretende a lei proteger tais locais, frequentados por grande quantidade de pessoas, algumas delas, em condições especiais. Portanto, o perigo à saúde pública é maior nestes locais, não exigindo a lei que o estabelecimento seja especialmente visado pelo agente.

Nesse sentido:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da lei $^{\circ}$ 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.(HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6^a T., DJe 15/12/2017).

"A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local (STJ. 6^a Turma. AgRg no Resp. 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017 STJ; 6^a Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016).

Diante da proximidade entre os locais, está latente que havia conhecimento da situação pelo acusado, razão pela qual as penas serão aqui elevadas em razão desse fator ($7 \text{ anos} + 1/6 = 8 \text{ anos e } 02 \text{ meses } /700 \text{ dias} + 1/6 = 816 \text{ dias}$).

O acusado é reincidente e possuidor de maus antecedentes, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no $\S$ 4 $^{\circ}$, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional

não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavaski, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR CARLOS ALBERTO ARRUDA DE CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde ele estiver.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos, derivados do comércio ilícito de drogas, em virtude dos fundamentos utilizados nesta decisão, a teor do artigo 62, da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, adote-se o necessário para remessa ao Senad e para o cumprimento da pena, promovendo-se as comunicações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 04 de agosto de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA